

1501694-35.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... ressaltando que para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o acusado seja flagrado comercializando drogas, bastando a prática de quaisquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL FIM DE AGIR. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501694-35.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501694-35.2021.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO, qualificado a fls. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque segundo a denúncia na noite de 04 de maio de 2021, por volta das 19h30, na Rua Eduardo Perez, nº 523, Loteamento Maria Christoni, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 2,63 g de cocaína, acondicionada em 13 (treze) porções individuais.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia, com rol testemunhal (fl. 1465/1466).

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 pela decisão proferida às fls. 1476/1479, após o que o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum, uma testemunha defensiva e tomado o interrogatório do réu, seguindo-se pelos debates orais, nos quais o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição, sustentando ter ficado comprado que a

droga apreendida no feito não pertencia ao réu. Alternativamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução máxima da pena (fls. 1533/1534 - arquivo digital).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado o crime de tráfico de drogas, a qual merece procedência haja vista que o acervo probatório reunido nos autos corrobora a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09; auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/17 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 1423/1426.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto, senão vejamos.

Em solo policial, o réu Anderson Gabriel Martim do Prado afirmou que estava no local dos fatos para fumar maconha com o amigo Matheus, mas ainda não havia comprado referido entorpecente, quando então os policiais chegaram e afirmaram "achamos um negócio aqui, quem que vai assumir?", negando, assim, relação com os entorpecentes apreendidos.

Em juízo, o réu manteve a versão de que teve a propriedade do entorpecente forjado pelos policiais, repetindo que estes encontraram drogas no centro comunitário, local onde estava acompanhado do amigo Mateus, cuja propriedade foi lhe atribuída. Destacou que havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas no mesmo local, quando igualmente foi forjado pelos policiais. Afirmou sofrer perseguição policial pois durante sua adolescência cometeu atos infracionais análogos a roubo e furto, inclusive chegou a ser internado na Fundação Casa.

Por sua vez, os policiais militares João Paulo Teixeira dos Santos e Cristiano Ribeiro de Camargo prestaram declarações uníssonas na fase extrajudicial, oportunidade em que narraram que durante patrulhamento de rotina visualizaram o acusado e outro indivíduo em atitude suspeita, ensejando a abordagem, os quais, por sua vez, ao perceber a aproximação policial empreenderam fuga, momento em que o réu Anderson dispensou 13 porções de cocaína.

Durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, os policiais repetiram a narrativa inicial, informando que realizavam patrulhamento pelas cercanias do CSU, local sobre o qual pairam diversas denúncias sobre a prática do tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e outro indivíduo, os quais iniciaram fuga para os fundos da instituição, quando foram interceptados pelo policial João Paulo, que viu o momento que um volume foi dispensado pelo denunciado. Durante a revista pessoal ao acusado, foram encontrados em sua posse R\$ 121,00 e um aparelho celular. Em seguida, recuperado o volume dispensado, verificaram tratar-se de 13 porções de cocaína. Relataram que o acusado chegou a atribuir a droga a Mateus, que também foi apresentado à autoridade policial. Destacaram que o réu é conhecido nos meios policiais por seu passado infracional e também por denúncias da prática do tráfico de drogas no centro comunitário onde se deram os fatos, local onde já havia sido preso anteriormente.

A testemunha defensiva Aparecido Carlos de Paiva relatou não ter presenciado os fatos e apenas teceu comentários abonatórios sobre o denunciado.

Como se vê, muito embora o réu tenha negado a prática delitiva, negando, inclusive, a propriedade dos entorpecentes apreendidos nos autos, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, coesos e harmônicos entre si, revelam que na ocasião dos fatos o réu foi visto pela equipe policial em local já conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas, onde o próprio réu, inclusive, já foi flagrado em outra ocasião praticando o tráfico de drogas, oportunidade em que ele, ao perceber a aproximação dos militares, tentou fugir, dispensando durante a fuga as substâncias ilícitas, a quais, no entanto, foram recolhidas após a

abordagem do denunciado.

Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaco decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Ademais, nota-se que a versão do réu, no sentido de que parte da droga foi forjada pelos policiais não restou minimamente comprovada nos autos, não tendo sido sequer demonstrada a existência de desavença ou desentendimento anterior entre o réu e os policiais militares que pudesse justificar a falsa acusação.

Dissertando acerca do ônus da prova no processo penal, a doutrina do jurista Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 596/597 nos ensina:

"De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II - art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. I 07, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um alibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação[...]

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova : para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável ; para a defesa, basta criar um estado de dúvida".

A respeito do mesmo assunto, cita-se o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E § 4.º DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE

COMPROVAR O ALEGADO. EXEGESE DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - JUÍZO DE CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Quando os elementos contidos nos autos de prisão em flagrante são corroborados em Juízo por declarações firmes e coerentes dos Policiais Militares que participaram da prisão do réu, forma-se, em regra, um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação. (TJSC, Apelação Criminal n. 0009103-64.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 29-10-2018)".

De acordo com esse entendimento, verifico que a Defesa não apresentou elementos mínimos para comprovar o álibi alegado ou mesmo para incutir dúvidas na convicção dessa magistrada quanto à propriedade das drogas atribuídas ao réu.

A mera alegação do réu, no sentido de que sofre perseguição policial por conta de seu passado infracional, não é suficiente para invalidar a ação policial. Pelo contrário, envolvimento pretérito do réu com prática delituosa em questão apenas reforça a convicção de que ele, já há muito tempo, tem envolvimento com a nefasta mercancia de drogas.

Diante deste contexto probatório, não há como se privilegiar a frágil versão defensiva em detrimento da acusatória, a qual, como visto, restou sobejamente demonstrada através das declarações dos policiais militares e demais circunstâncias que envolveram a prisão do réu, em especial pelos extensos laudos periciais insertos às fls. 124/1398.

Portanto restando suficientemente demonstrado que toda droga pertencia ao acusado, passo a análise de sua destinação, ressaltando que para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o acusado seja flagrado comercializando drogas, bastando a prática de quaisquer dos verbos constantes do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, veja-se o seguinte arresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESPECIAL FIM DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6.368/76, não se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas estabelecidas no dispositivo.

2. De outro lado, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito descrito no artigo 16 da Lei de Tóxicos somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo uso própria da substância, elementar subjetivo especial do tipo.

3. Recurso especial conhecido e provido

(REsp. 812.950/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008).

No caso, foram apreendidas 2,63 gramas de cocaína, na forma de treze porções, quantia que embora não se mostre exorbitante, constitui como forte indício da traficância, posto que as pequenas porções facilitam a venda a terceiros. Nesse sentido:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papelotes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Ademais, além do entorpecente, foi apreendida a quantia de R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em dinheiro na posse do acusado, cuja origem não restou suficientemente esclarecida, sendo possível concluir, diante do contexto dos autos, que o montante restante foi obtido através da venda de drogas.

Soma-se a isso os diversos diálogos transcritos no laudo pericial de fls. 124/1398, mantidos pelo réu com terceiros via whatsapp, os quais revelam algumas negociações ilícitas de droga (fls. 396; 401 e 1397). Destaca-se, dentre os diálogos, aquele transcrito às fls. 408, no qual o acusado menciona o CSU, de modo a corroborar o teor da prova oral, no sentido de que o denunciado usava o centro comunitário como ponto de venda de drogas.

Todas estas circunstâncias da prisão em flagrante, aliado ao conjunto probatório consubstanciado principalmente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, comprovam, de forma inequívoca, que o acusado se dedicava à nefasta mercancia de drogas.

Portanto, presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do réu deve ser condenado e submetido ao cumprimento da lei penal, por ser medida de justiça. Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é insita ao tipo penal. O réu não registra antecedentes criminais que consubstanciem maus antecedentes (fls. 42/43) e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço. Nesses termos, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Incide a atenuante da menoridade relativa, contudo, sem reflexo na reprimenda, haja vista o teor da Súmula 231, do STJ. Assim, mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Finalmente, na última fase, considerando a primariedade técnica do denunciado e a ausência de indícios nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo possível a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, no entanto, a redução deve ser modulada de acordo com a natureza das drogas apreendidas. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. (HC 440.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) destaquei.

Destarte, diante da apreensão de cocaína, de alto poder viciante e nocivo à saúde humana, reduzo a pena anteriormente fixada em 1/2 (metade) alcançando o montante de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena esta que converto em definitiva por não encontrar circunstância modificadora aplicável.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime.

Em relação à definição do regime inicial para o cumprimento da pena corporal, anoto que o tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a solidificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ficando afastada a incidência das disposições da Lei n.º 8.072/90. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu em sede de repercussão geral que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos

parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal"(RE 1052700, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgamento em 2.11.2017, DJe de 1.2.2018, Tema 972).

Importante ressaltar, outrossim, a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ no julgamento do HC 596.603-SP, que proibiu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena para o crime de tráfico na modalidade privilegiada.

Seguindo tais orientações e atenta aos princípios da individualização e da suficiência (artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal), verifico a concomitância de ação penal da mesma natureza e a natureza do entorpecente traficado afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando ao réu, razão pela qual fixo ao réu o regime intermediário - semiaberto.

Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu permaneceu encarcerado preventivamente entre a data do flagrante (04/05/2021) até a audiência instrutória (30/11/2021), tempo que se mostra suficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 16% da pena, conforme art. 112, I, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial ABERTO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ANDERSON GABRIEL MARTIM DO PRADO, qualificado a fls. 05, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No tocante aos valores apreendidos no feito, não tendo sido comprovado a origem lícita, conclui-se diante do contexto probatório que foram obtidos através do tráfico ilícito de drogas, o que determina o perdimento na forma da lei. Assim, declaro a perda dos valores em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06.

Quanto ao(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) no feito, não sendo requerida a restituição, no prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, fica, desde já, determinada a liberação, oficiando-se ao r. Juízo responsável pelo setor de depósito, para que promova a destinação legal, na forma dos artigos 516, § 2º, e 517, das NSCGJ e 123, do CPP. Expeça-se o necessário. Considerando o regime efetivamente fixado na presente decisão, permito ao réu que aguarde o resultado de eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento à Procuradoria do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, ficando consignado que o pagamento da multa imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido parcelamento e c) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

PIC.

Ourinhos, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA